

1500223-09.2020.8.26.0605
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: João Luis Monteiro Piassi
Comarca: Ilha Solteira
Foro: Foro de Ilha Solteira
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 12/04/2022
... tese de nulidade.

Da Imputação do Crime de Tráfico de Entorpecentes praticado pelos Srs. Alan Seixas da Silva Santos e Leonardo Silva Santos.

O crime de tráfico de drogas está previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ilha Solteira
Foro de Ilha Solteira
2ª Vara
Avenida Brasil Norte, 1680, Ilha Solteira-SP - cep 15385-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500223-09.2020.8.26.0605 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500223-09.2020.8.26.0605
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2200605/2020 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 13008379 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 970/20/111 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA, 2200605 - DEL.POL.ILHA SOLTEIRA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ALAN SEIXAS DA SILVA SANTOS e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Monteiro Piassi

I - RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de processo-crime proposto pelo Ministério Público Estadual contra os Srs. Alan Seixas da Silva Santos e Leonardo Silva Santos.

Na denúncia, narra-se que em data que não se pode precisar, mas até o dia 14 de agosto de 2020, às 21h15, no Passeio Laguna, nº 223, Zona Sul (Morumbi), nesta cidade e comarca, os denunciados, ouvidos às fls. 06/07 e qualificados às fls. 16 e 20, associaram-se para o fim de cometerem reiteradamente o crime de tráfico de drogas, pois, guardavam e mantinham em depósito, para a entrega e consumo de terceiros, 03 (três) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 5.94 gramas, e 02 (duas) porções de crack, com peso bruto aproximado de 23.93 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos periciais de fls. 185/187 e 188/190.

Somando as cédulas encontradas em poder dos denunciados, totalizou-se a importância de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais). O dinheiro apreendido sem origem lícita declarada, a quantidade de invólucros e a forma de acondicionamento dos entorpecentes evidenciam que realmente se destinavam à atividade de tráfico.

Prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 102/106).

Posteriormente, foi deferida liberdade provisória (fl. 151).

Auto de exibição/apreensão às fls. 30/32.

Os laudos de constatação provisória (fls. 24/25 e 28/29) e laudo pericial definitivo tiveram resultado positivo para "Cocaina" (fls. 185/187 e 188/190).

Laudos IC - Objetos (facas, pratos e sacos plásticos) às fls. 191/199.

Laudos IC - Telefone celular dos réus.

Recebida a denúncia em 11 de agosto de 2021 (fls. 379/381).

O réu Leonardo foi citado pessoalmente (fl. 301).

O réu Alan foi citado pessoalmente (fl. 378).

Os réus ofereceram defesa escrita (fls. 302/325).

Mantido o recebimento da inicial (fl. 379/381).

Verificado conflito de interesses na defesa técnica (fl. 460), foi oferecida nova defesa escrita pela defesa de Leonardo Silva Santos (fls. 471/484).

No curso da instrução (fl. 574), realizou-se oitiva em audiência de testemunhas e dos réus.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, enquanto as defesas sustentaram a absolvição dos réus (fls. 593/631 e 635/654).

Folha de Antecedentes Penais do réu Alan (fls. 450/452) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 453/454).

Folha de Antecedentes Penais do réu Leonardo (fl. 455/457) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 458/459).

É o relatório.

Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Preliminar de Nulidade por Invasão de Domicílio

Não há se falar em violação do domicílio e nulidade da prova obtida.

No RE 603616, o STF, em decisão paradigmática, estabeleceu:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.

Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori.

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado

judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

A jurisprudência do STJ tem extraído do acórdão paradigma que: (i) "(0) ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 671.736/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/06/2021, DJe 28/06/2021); e (ii) "(A)fere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência" (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

No presente caso, as provas produzidas dão conta de que os policiais estavam em patrulhamento quando passaram por estabelecimento comercial conhecido por ser ponto de compra e venda de drogas, momento em que visualizaram movimentação suspeita. Ato contínuo, localizaram drogas e foram convidados a adentrar a residência pela esposa de um dos réus, onde lograram encontrar mais da substância estupefaciente. Em situações análogas o STJ tem entendido pela validade do flagrante e invasão do domicílio: (i) "(A)pós o recebimento de denúncia anônima, confirmado as suspeitas dos agentes da lei, estes realizaram campana e, só depois, se dirigiram à porta da residência e chamaram pelo paciente. (...) De fato, ao cotejar da moldura fática traçada no acórdão impugnado e a normatividade aplicável à espécie, não se divisa nenhuma antijuridicidade a ser reparada.". (AgRg no HC 652.127/SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. em 25/05/2021, DJe 31/05/2021); (ii) "(I)nciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes deixados na rota de fuga do paciente, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio" (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, j. em 22/06/2021, DJe 28/06/2021); (iii) "(A)demais, embora a busca no referido local tenha se originado de denúncia anônima acerca da prática do tráfico, os agentes de segurança realizaram breve campana na área, quando foi possível verificar um fluxo intenso e suspeito de pessoas e automóveis, justificando a entrada no imóvel. Logo, não há como acolher a tese de violação domiciliar" (HC 538.832/MA, Rel. Min. Riberiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/05/2021, DJe 21/05/2021). Observe, por oportuno, que a decisão proferida no HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021, foi anulada por decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes no RE 1.342.077, a qual assentou:

"(...) a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, não só transformando o presente habeas corpus individual em um habeas corpus coletivo, como também estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes e determinando em abstrato e com efeitos vinculantes e erga omnes a todos os órgãos da administração de segurança pública do País – estaduais, distrital e federal – verdadeira obrigação de fazer inexistente na Constituição Federal e na legislação, como se verifica nos itens 7.2, 12 e 13 da Ementa do referido julgado:

'7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em

vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. (...)

12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.

13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal.'

(...)

Incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE

Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa) (...)."

Com efeito, nada há nos autos a respaldar a tese de violação de domicílio, o que macularia as provas produzidas, razão pela qual afasto a respectiva tese de nulidade.

Da Imputação do Crime de Tráfico de Entorpecentes praticado pelos Srs. Alan Seixas da Silva Santos e Leonardo Silva Santos.

O crime de tráfico de drogas está previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 contempla 18 núcleos, tratando-se de tipo misto alternativo, ou seja, ainda que o agente pratique mais de um núcleo, a ele será imputado apenas um delito. Além disso, da leitura do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conclui-se que o crime pode restar configurado ainda que a alienação

da droga se dê gratuitamente, mas desde que a conduta seja praticada sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ato contínuo de análise do tipo penal, deve-se observar que a lei não exige para a configuração do crime de tráfico a presença de elemento subjetivo especial do tipo, como o faz para o delito de posse de droga para consumo próprio. Nesse sentido, a lição de Renato Brasileiro de Lima, em seu Legislação Criminal Especial Comentada (2021, p. 1.068):

"Apesar de a expressão 'tráfico de drogas' estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, fato é que a tipificação desse crime dispensa a presença de qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de praticar um dos 18 (Dezoito) verbos constantes do art. 33. A propósito, ambas as Turmas Criminais do STJ têm precedentes no sentido de que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Portanto, diversamente do crime do art. 28 da Lei de Drogas, que se caracteriza pela presença do especial fim de agir de o agente trazer a droga consigo para consumo pessoal, sendo considerado, pois, tipo incongruente (ou congruente assimétrico), os crimes de tráfico de drogas são espécies de tipos congruentes, vez que há uma perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, isto é, são infrações desprovidas de qualquer outro elemento subjetivo - o chamado dolo específico da doutrina tradicional (ou especial fim de agir)."

No sentido que se vem de expor, veja-se o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

As substâncias apreendidas foram identificadas pelos peritos como "Cocaína", definida como droga pelo art. 66 da Lei nº 11.343/2006 e pela Portaria SVS/MS nº 344/1998.

O auto de apreensão e a prova oral produzida em juízo provam que estavam na posse

de Leonardo para fins de tráfico, ao passo que estavam na posse de Alan para fins de consumo.

O policial militar, o Sr. Paulo, disse que estava em patrulhamento, junto ao seu Sargento, o policial Nunes, quando avistaram um carro suspeito na rua dos fatos. O carro, em si, não tem relação com o quanto foi apurado posteriormente, mas chamou a atenção dos policiais, os quais decidiram abordá-lo.

Ao dirigirem-se na direção do veículo, antes de qualquer abordagem, avistou o Sr. Leonardo arremessando um saquinho para dentro de um salão de cabeleireiro. Após esta conduta é que abordaram individualmente os averiguados, que estavam em frente a um local sobre o qual havia denúncias de tráfico de drogas (fl. 23).

Ao realizar a busca pessoal, nada encontraram; mas a esposa de um dos réus, a Sra. Ana Julia, saindo de dentro do salão de que era proprietária, franqueou a entrada aos policiais, que lograram encontrar o saquinho que havia sido dispensado.

No mesmo sentido o testemunho do Sargento Nunes, acrescentando o relato da esposa de Alan, no sentido de que desde a chegada de Leonardo em sua casa, notou que este se dedicava ao tráfico e que imaginava que Alan tinha parado de usar drogas.

A Sra. Ana Julia, em juízo, negou tenha franqueado a entrada dos policiais no domicílio – ao revés, disse ter sido vítima de violência policial. Negou, ademais, tenham sido encontradas drogas no salão (afirmou que os policiais não mostraram nada para ela).

Confirmou, porém, que no quarto de Leonardo foram encontradas as drogas e dinheiro na gaveta do guarda-roupas. Não acompanhou as buscas no quarto de Alan, somente na de Leonardo, mas soube que foram encontradas drogas também no seu aposento. Disse que Alan era usuário de drogas, especificamente cocaína, mas achava que ele, ao tempo dos fatos, já tinha parado. Neste ponto, deve ser notada a confluência do testemunho de Ana Júlia e o de Nunes.

A testemunha de defesa, Iuri, por sua vez, esteve presente no local dos fatos, e corroborou os fatos alegados pela defesa de Alan no sentido de que o dinheiro encontrado era relativo ao pagamento de um curso ministrado por Alan a ele.

Em seu interrogatório, o réu, o Sr. Leonardo Silva Santos, narrou que: havia droga (crack) em seu quarto, bem como os demais petrechos apreendidos. Nega a traficância. Em relação ao dinheiro disse que era proveniente de seu trabalho.

Fazia uso do entorpecente uma vez ao dia, fora da residência, nas proximidades de uma praça. Utilizava um cachimbo, o qual ficava armazenado na aludida praça. Seus familiares não tinham conhecimento da sua condição de usuário. Não tem antecedentes criminais. Sua avó lhe fornecia dinheiro para comprar droga. Não acompanhou as buscas da equipe policial.

Em seu interrogatório, o réu, o Sr. Alan Seixas da Silva Santos, narrou que: "nem" todos os fatos são verdadeiros. É usuário de entorpecentes. Confirma que havia em seu guarda-roupas uma porção de cocaína para uso pessoal. Nega qualquer envolvimento com tráfico de drogas. Não sabe informar o nome da pessoa que lhe vendeu a droga, acrescentando que a adquiriu na Praça dos Paiaguás. Não tinha conhecimento dos entorpecentes encontrados na residência de seu irmão. Reitera que é usuário de drogas. Asseverou que no dia do ocorrido fez uso de entorpecente. Não acompanhou as buscas policiais, alegando que foi retirado "para fora" pelo agentes. Quanto ao dinheiro apreendido disse que é proveniente de seu trabalho.

Bem analisada a prova oral, entendo que os elementos que apontam para a culpa de Alan são frágeis; embora o mesmo não possa ser dito do réu Leonardo.

Com efeito, Leonardo foi visto atirando um saco de drogas e as drogas e petrechos para o tráfico foram encontradas em seu quarto. No quarto de Alan foi apreendido tão somente uma porção de droga – e os autos dão conta de que era realmente usuário.

No que diz respeito à Alan, as provas convencem que estava se dedicando a uma nova vida, como barbeiro, ministrando cursos – embora a presença de Leonardo possa tê-lo influenciado negativamente, no sentido de retomar o uso da cocaína. Parte do dinheiro encontrado, aliás, R\$ 500,00, tiveram sua origem comprovada em curso que ministrara para Iuri (fl. 355).

Anoto, por fim, que do interrogatório de Leonardo não se extrai elementos a dar suporte a tese de que as drogas eram destinadas ao seu uso, diante da inconsistências das suas falas e do fato de que nada foi encontrado no sentido de

demonstrar o uso do crack por ele.

Por isso, merece crédito a narrativa policial, no que diz respeito à Leonardo, desprovida de incoerências e de suspeita de interesse dos milicianos na causa (não há razão para acusarem injustamente os réus). Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

Precedentes.

- A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante - quando estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como de venda de drogas, ocasião em que o paciente ao avistar a chegada da polícia, iniciou uma fuga, havendo sido detido pelos agentes, portando uma pochete contendo 19 porções de maconha, pesando 57,9 gramas e 69 eppendorfs de cocaína, pesando 19,5 gramas (e-STJ, fl. 93) -, Some-se a isso, o fato de o próprio paciente haver confessado a mercancia aos policiais no momento da abordagem.

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO.CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente.

2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína ao corréu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.

3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.

4. Não caracteriza bis in idem a utilização das circunstâncias da quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias

concretas, sendo imprópria a via do habeas corpus à revisão do entendimento.

5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP.

6. Ordem denegada.

(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018)

Desta feita, reputo que os entorpecentes estavam na posse dos réus.

No caso, a quantidade e variedade de droga apreendida, as circunstâncias da apreensão (parte ré em local público, conhecido como ponto de venda de drogas, sem qualquer sinal de consumo de entorpecente) e a forma de acondicionamento da droga (pequenas porções prontas para a venda) demonstram que era destinada ao consumo de terceiros, e não próprio. Assim, caracterizado o crime de tráfico em relação à Leonardo.

De mais a mais, é ponto pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o princípio da insignificância não se aplica aos delitos do art. 33, caput, e do art. 28 da Lei de Drogas, pois tratam-se de crimes de perigo abstrato ou presumido (HC 461377/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2018, DJe 22/11/2018; EDcl no HC 463656/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04/10/2018, DJe 24/10/2018). Por todos, veja-se o seguinte precedente do STF:

"HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Ante a envergadura maior do habeas, voltado a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, não há como deixar de adentrar-se à matéria de fundo, pouco importando que direcione à análise do cabimento e processamento de recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, ainda que direcione à análise de fatos e provas. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – IRREGULARIDADE – CONSEQUÊNCIA. A irregularidade na representação processual implica a inexistência do ato de interposição, inviabilizando o conhecimento pelo Órgão judicante. COMPETÊNCIA – AFERIÇÃO – JUÍZO. A competência há de ser aferida considerado o Juízo, revelando-se impróprio cogitar de fixação em relação à pessoa do magistrado. PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA – REPERCUSSÃO – AÇÃO PENAL. Eventual ausência de justa causa para a formalização do flagrante não repercute na validade da ação penal. TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.

(HC 129489, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019)"

No tocante ao Sr. Alan, entendo ser possível proceder à emendatio libelli, forte no art. 383 do CPP, para que responda pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas, ciente de que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, sendo certo que a denúncia descreve o fato atinente à posse de drogas.

Em relação ao réu, o Sr. Leonardo, não incidem quaisquer circunstâncias agravantes. Incide, porém, a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), uma vez que na data do fato, 14/08/2020, o agente Leonardo era menor de 21 (vinte e um) anos.

Dispõe o art. 33, §4º, da Lei

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser

reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre a figura do tráfico privilegiado, cumpre firmar, desde já, algumas premissas, colhidas da pacífica jurisprudência dos tribunais superiores:

(i) a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas só pode ser aplicada se todos os requisitos, cumulativamente, estiverem presentes (HC 510077/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/06/2019, DJe 05/08/2019; AgRg no REsp 1449194/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/09/2017, DJe 04/10/2017);

(ii) a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa (AgRg no HC 668.599/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021; AgRg no REsp 1924209/MG, Rel. Min. Feliz Fischer, Quinta Turma, j.m 13/04/2021, DJe 26/04/2021).

(iii) não é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (STF, HC 184.979-AgR/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, DJe 07/08/2020; REsp 1916596/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

(iv) é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando há condenação simultânea do agente nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa (AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18/06/2019, DJe 02/08/2019; AgRg no AREsp 1327778/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.14/05/2019, DJe 24/05/2019);

(v) diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 seja modulada em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito (HC 477280/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/02/2019, DJe 26/02/2019; HC 458735/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/10/2018, DJe 23/10/2018);

(vi) as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena (Repercussão Geral Tema 712). Assim, a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena-base e para afastar a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob pena de caracterizar bis in idem (AgRg no HC 497047/SP, Rel. Min. Rogério SCchietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/05/2019, DJe 25/06/2019; HC 472052/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

(vii) a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem, tratando-se de hipótese diversa da Repercussão Geral - TEMA 712/STF (HC 510248/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2019, DJe 13/06/2019; HC 491328/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.18/06/2019, DJe 01/07/2019);

(viii) reconhecida a inconstitucionalidade da vedação prevista na parte final do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, inexistente óbice à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (HC 482234/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.em 06/06/2019, DJe 14/06/2019; HC 482626/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/03/2019, DJe 09/04/2019); e

(ix) o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo (Tese revisada sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015 - TEMA 600; AgRg no HC 485746/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2019, DJe 17/06/2019; AgRg no HC 485237/SP, Rel. Min.

Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

No presente caso, tem-se que o réu, o Sr. Leonardo, é tecnicamente primários e não possui maus antecedentes. Ademais, nada há nos autos a indicar que se dedique à atividade criminosa ou que integre organização criminosa. Em que pese a natureza deletéria da droga que trazia consigo, a quantidade é ínfima. Desta feita, faz jus à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3. Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA DROGA. DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressalva deste relator.

3. A quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente 9,9 g de crack e 4,1 g de cocaína, mesmo considerada sua natureza deletéria, não se mostra excessivamente elevada a ponto de, por si só, levar à conclusão de que ele se dedica a atividades criminosas, notadamente quando verificado que, ao tempo do delito, era tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes e que, no contexto da prisão em flagrante, não foram apreendidos outros apetrechos destinados à traficância.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 641.362/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Da Imputação do Crime de Associação para o Tráfico de Drogas Praticado pelo Sr(a) (s). Alan Seixas da Silva Santos e Leonardo Silva Santos

Dispõe o art. 35 da Lei de Drogas:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Para a correta aplicação do dispositivo acima, faz-se necessário firmar algumas premissas, auridas da jurisprudência do STJ:

i) para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência (HC 479977/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/05/2019, DJe 23/05/2019; HC 493766/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. em 07/05/2019, DJe 15/05/2019);

ii) para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é irrelevante apreensão de drogas na posse direta do agente (HC 441712/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 21/02/2019, DJe 12/03/2019; RHC 93498/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 08/05/2018, DJe 21/05/2018); e

iii) o crime de associação para o tráfico de não figura no rol taxativo de crimes hediondos ou de delitos a eles equiparados (HC 408457/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 03/10/2017, DJe 16/10/2017; HC 430217/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 18/09/2018, DJe 01/10/2018).

No mesmo sentido dos entendimentos acima, é a doutrina de Masson e Marçal, em seu Lei de Drogas: Aspectos Penais e Processuais (2021, pp. 125 e 126):

"O núcleo do tipo é 'associarem-se', ou seja, aliarem-se, reunirem-se, congregarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei.

A locução 'reiteradamente ou não', prevista no caput do art. 35, pode levar o intérprete à errônea conclusão segundo a qual a mera reunião de duas pessoas, sem vínculo associativo (estabilidade), para o fim de praticar qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 da Lei de Drogas, já seria suficiente para caracterizar a associação para o tráfico. De fato, essa situação configura concurso eventual de pessoas (coautoria ou participação), e não o crime de concurso necessário do art. 35 da Lei 11.343/2006 que, inegavelmente, reclama a affectio criminis societatis.

No art. 35 da Lei de Drogas, portanto, é imprescindível o liame associativo, revestido de estabilidade e permanência entre seus integrantes. Em outras palavras, o acordo ilícito entre duas ou mais pessoas deve versar sobre uma duradoura, mas não necessariamente perpétua, atuação em comum para o fim de cometer qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 da Lei 11.343/2006."

Em arremate, o escólio de Nucci, em seu Leis Penais e Processuais Penais Comentadas (2021, p. 426 e 427):

"(...) associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento pretérito, cuidava-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa teria justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico. Porém, alteramos nossa posição, tendo em vista o critério adotado pela Lei do Crimes Hediondos, que, embora não seja o ideal, aponta com taxatividade quais são os crimes hediondos e figuras a eles equiparadas. No art. 2º, caput, consta apenas tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. O ideal seria o juiz, possuindo uma definição de crime hediondo, fornecida em lei, qualificar o delito como hediondo, no caso concreto. Sob outro aspecto, a associação criminosa há de ser estável e permanente. Do contrário, seria somente um concurso de pessoas. (...) o crime de associação é formal, voltando-se contra o bem jurídico primário consubstanciado na paz pública. Logo, torna-se desnecessário apreender a droga ou examiná-la. A materialidade (prova da existência da infração penal) pode dar-se por qualquer outro meio lícito."

No caso trazido à apreciação deste juízo criminal, as provas produzidas não permitem inferir a estabilidade da associação criminosa, requisito indispensável, à luz da jurisprudência, para sua configuração.

No mais, não restou demonstrada a prática do delito de tráfico por parte de Alan Seixas, donde a inexistência do concurso necessário.

Responsabilidade Penal

Tudo bem examinado e ponderado, deve ser observado, ainda nesta sede, que nada alegou a defesa que permitisse afastar a antijuridicidade da conduta delitiva imputada à parte ré, a qual, aliás, agiu com entendimento, autodeterminação e ciência da ilicitude do fato praticado, quando era certamente de se lhe exigir a adoção de conduta diversa.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o Sr. Leonardo Silva Santos praticou o delito de Tráfico de Droga e o Sr. Alan Seixas da Silva Santos o de Posse de Drogas para Consumo Pessoal, devendo ser responsabilizados penalmente pela suas condutas.

III – FIXAÇÃO DA PENA

Dosimetria da Pena do Crime de Tráfico de Drogas praticado pelo Sr. Leonardo Silva Santos

Em atenção ao Princípio da Individualização das Penas (art. 5º, inc. XLVI, da CF/88) e ao Sistema Trifásico (art. 68 do CP), passo à dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei 11.343/06), deve ser observado que a natureza altamente deletéria da substâncias apreendidas deve ser valorada negativamente, ainda que relativamente pouca a quantidade. No mais, tem-se que:

i) Na análise da culpabilidade, deve-se examinar, na lição de Bitencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 788), "(...) a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da

conduta praticada, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu". Nada há nos autos que permita concluir por um grau diferenciado de censura da parte ré. Em outras palavras, o grau de censura necessário já é alcançado pelo mínimo da pena aplicada. Assim, a culpabilidade deve ser valorada como circunstância judicial neutra.

ii) Na análise dos antecedentes, deve-se examinar a vida pregressa do réu na seara criminal. Antes, porém, de proceder a este exame, faz-se oportuno estabelecer alguns parâmetros - à luz da doutrina e da jurisprudência dominantes -, a serem observados.

Segundo Masson, em seu Código Penal Comentado (2021, p. 416), para a caracterização dos maus antecedentes, "basta a existência de uma condenação penal definitiva", sendo que o "trânsito em julgado da condenação pode ser anterior ou posterior à prática do novo delito". Assim, é suficiente que o antecedente criminal: (i) seja relativo a fato anterior à infração em julgamento (STJ. 5ª Turma. HC n. 268.762/SC, Min. Regina Helena Costa, DJe 29/10/2013; STJ. 6ª Turma. HC 189.385-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/2/2014); e (ii) tenha se formado definitivamente (transitado em julgado) antes do julgamento do crime em que ele é valorado.

Nesta ordem de ideias, pode ocorrer de a parte ré possuir uma ou mais condenações definitivas por fatos praticados antes do que está sendo atualmente julgado.

Cumprido, portanto, estabelecer uma casuística a este respeito.

Em havendo uma única condenação por infração penal anterior, registrada no histórico criminal da parte ré, devem-se distinguir ao menos duas situações: (i) se o trânsito em julgado da condenação pelo fato pretérito for posterior ao fato em julgamento, então estar-se-á diante de um mau antecedente; ou (ii) se tanto o fato pretérito, quanto o trânsito em julgado da condenação a ele relativa, forem anteriores ao fato em julgamento, então estar-se-á diante da reincidência em sentido técnico (art. 63 do CP), salvo se houver transcorrido o prazo depurador (art. 64, inc. I, do CP), hipótese em que a condenação definitiva anterior será valorada como antecedente criminal, observado o sistema da perpetuidade, abaixo examinado.

Em havendo duas ou mais condenações por infrações penais anteriores, registradas no histórico criminal da parte ré, pode ocorrer de: (i) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado (a) após o trânsito em julgado de uma condenação por delito anterior, caso em que essa será valorada como reincidência; e (b) após a prática de outro delito, cujo trânsito em julgado sobreveio antes do julgamento atual, caso em que essa será valorada como mau antecedente; ou (ii) a prática da infração penal sob julgamento ter se dado após o trânsito em julgado de duas ou mais condenações por delitos anteriores, caso em que uma poderá ser considerada como reincidência e a outra (ou mais) como mau antecedente, observado o entendimento consagrado na Súmula 241 do STJ ("A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial").

Aqui, cabe observar que, condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema Repetitivo 1077, REsp 1794854/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Um resumo do quanto exposto nos é oferecido por Masson (idem, p. 444): "(...) se o réu possui mais de uma condenação definitiva, uma pode ser utilizada como mau antecedente e a outra como agravante genérica (reincidência, não se falando em bis in idem. Na hipótese de múltiplas condenações definitivas, o magistrado deve utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, se for o caso, e as demais como maus antecedentes."

Sobre o momento da condenação penal definitiva utilizada como mau antecedente, vale observar que a ela não se aplica o período depurador de que trata o art. 64, I, do CP, conforme decidido pelo STF, em sede de Repercussão Geral, RE 593.818, Tema 150. Em outras palavras, o sistema penal adota a regra da perpetuidade em matéria de

antecedentes (nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: 5ª Turma, AgRg no HC 558.745/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 15/09/2020, DJe. 21/09/2020; e 6ª Turma, AgRg no REsp 1790225/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/09/2020, DJe. 22/09/2020). Portanto, é possível considerar qualquer condenação anterior (desde que já transitada em julgado e relativa a fato praticado antes daquele atualmente em julgamento), ressalvadas aquelas por atos infracionais pretéritos, pois que não configuram "crime" em sentido estrito (STJ, 5ª Turma, HC 623.117/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021, DJe. 12/02/2021; e STJ, 6ª Turma, REsp 1702051/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06/03/2018, DJe. 14/03/2018).

Por fim, conforme pacífico entendimento do STJ, "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência" (Súmula 636 do STJ), o que, contudo, não afasta a possibilidade de serem eles comprovados por outros meios (STF, 1ª Turma, HC 162.548, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/06/2020, DJe. 03/07/2020; e STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 448.972/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2018, DJe. 24/08/2018). Veda-se, todavia, por força do Princípio da Presunção de Inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF/88), a utilização de "inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base" (Súmula 444 do STJ).

Postas estas premissas, ao analisar a Folha de Antecedentes Criminais (fls. 97 e 455/457) / Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 99/101 e 458/459) do réu Leonardo, não se constata nenhuma condenação definitiva por infração praticada antes desta em julgamento. Assim, os antecedentes devem ser valorados como circunstância judicial neutra.

iii) Na análise da conduta social, consoante a já clássica lição de Bittencourt, em seu Tratado de Direito Penal (vol. 1, 2017, p. 791), deve-se examinar "o conjunto do comportamento do agente em seu meio social, na família